



Roj: **STS 5385/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5385**

Id Cendoj: **28079130022025100300**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **17/11/2025**

Nº de Recurso: **5786/2023**

Nº de Resolución: **1463/2025**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **ISAAC MERINO JARA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAN 2871/2023,**
ATS 6247/2024,
STS 5385/2025

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1.463/2025

Fecha de sentencia: 17/11/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 5786/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 21/10/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara

Procedencia: Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 5786/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1463/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

D. Manuel Fernández-Lomana García

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.^a Sandra María González de Lara Mingo

D.^a María Dolores Rivera Frade

En Madrid, a 17 de noviembre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación número 5786/2023 interpuesto por la Administración General del Estado representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento 884/2019, sobre el impuesto sobre la Renta de No Residentes, ejercicios 2011 a 2013.

Han comparecido, como parte recurrida, la entidad R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., representada por el Procurador D. Antonio Miguel Ángel Araque Almendros.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso núm. 884/2019, interpuesto por R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G. contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 8 de octubre de 2019; relativa al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, ejercicios 2011 a 2013.

SEGUNDO.- *Hechos relevantes.*

R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG es una entidad aseguradora residente en Alemania, cuyas actividades están dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) [« Directiva 2009/138»]. En el marco de su actividad, invirtió en sociedades cotizadas españolas y percibió dividendos en los ejercicios 2011 a 2013. Sobre dichos dividendos se practicó una retención en concepto de Impuesto sobre la Renta de No Residentes [«IRNR»].

El 20 de febrero de 2015, presentó las autoliquidaciones correspondientes a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente durante los ejercicios 2011 a 2013, solicitando la devolución de las cantidades retenidas en exceso, a cuenta del IRNR, en relación con los dividendos de fuente española.

La Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, notificó a la solicitante, propuestas de liquidación con las que inició los correspondientes procedimientos de comprobación limitada. La entidad presentó alegaciones a tales propuestas.

Tras su recepción, la AEAT notificó a la interesada, las resoluciones con liquidación provisional desestimando las solicitudes de devolución formuladas en los modelos 210.

Asimismo, de forma simultánea, el 20 de febrero de 2015, la reclamante presentó ante la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, solicitud de rectificación de las autoliquidaciones presentadas.

Frente a las anteriores liquidaciones provisionales, así como, frente al acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación, notificado el día 19 de noviembre de 2015, la entidad interesada interpuso recurso de reposición.

La resolución de dicho recurso fue notificada los días 1 de diciembre de 2015, 16 de febrero de 2016, desestimando el mismo por las razones que figuran en el acuerdo, similares a las que fundamentaban los actos dictados por la Administración Tributaria contra los que se interponía dicho recurso.

Contra las resoluciones desestimatorias del recurso de reposición la entidad reclamante interpuso las correspondientes reclamaciones económico-administrativas. En esas reclamaciones formuló alegaciones, basadas, fundamentalmente, en la vulneración de la libre circulación de capitales y la discriminación de las aseguradoras no residentes.

El TEAC desestimó las reclamaciones en resolución dictada el 8 de octubre de 2019. En su fundamento de derecho cuarto argumenta que la deducción fiscal pretendida se puede negar con un doble enfoque: *«En primer lugar, si nos fijamos en que la actividad realizada en España no es la actividad aseguradora, sino tanto sólo una concreta inversión financiera, una colocación de capital [...] No serían deducibles, por tanto, los gastos propios de la actividad aseguradora que no se ejerce en España, como son las provisiones técnicas que se pretenden. [...] En segundo lugar, si se aceptase que hemos de fijarnos en el hecho de que la inversión realizada en España forma parte de la actividad aseguradora de la entidad [...] tampoco procede la deducción que se pretende [...], ya que no consta una relación directa entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretende deducirse de dichos rendimientos.»*

Por lo que se refiere al caso objeto de estudio -prosigue el TEAC- la reclamante se limita a remitirse a los informes, adjuntos a las alegaciones formuladas ante el propio TEAC, para explicar el funcionamiento del negocio asegurador en Alemania, sus principales aspectos jurídico-fiscales y acreditar la naturaleza de las pólizas suscritas con los tomadores. Los informes elaborados por Price Waterhouse Coopers A.G. y aportados por la entidad reclamante contienen aspectos relativos al desarrollo de la actividad aseguradora en Alemania, diferenciando dos tipos de actividades en el negocio asegurador de la reclamante, indicando para cada una de ellas las características de los contratos de seguro suscritos con los tomadores, así como la forma de determinación del beneficio y la imposición sobre el mismo, en base a lo dispuesto en la legislación alemana. Parece desprenderse -continúa el TEAC- de los citados informes que la "actividad de seguro de vida vinculada a fondos" se articula a través de pólizas que instrumentan "inversiones de capital por cuenta y riesgo de los titulares de seguros de vida" y, sin embargo, la "actividad de seguro de vida formadora de capital" se materializa a través de pólizas de características distintas a las anteriores en lo relativo a la transferencia del riesgo a los titulares y, por ende, a la naturaleza de la provisión técnica dotada y a la cuantía de la misma. También se desprende de dichos informes -según el TEAC- que la entidad realizó ambos tipos de actividad en los periodos controvertidos formalizando, por tanto, pólizas de distinta naturaleza y, en consecuencia, dotando provisiones técnicas de diferente carácter en función del nivel de riesgo asumido por el tomador.

Para que la provisión técnica dotada pueda considerarse de acuerdo con el artículo 24.6 del TRLIRNR, un gasto con un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España -sigue diciendo el TEAC-, se exige que la labor probatoria llevada a cabo por la reclamante, a tenor la obligación impuesta por el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, acredite:

«En primer lugar, la realización de una actividad aseguradora en la que el riesgo se traslade de forma íntegra (no en un porcentaje importante sino al cien por cien) al tomador de la póliza que asume, en consecuencia, todo el beneficio o pérdida que derive de la inversión. La acreditación de la formalización de dichos contratos exige la exhibición de la póliza o del documento contractual en el que se formalicen los mismos. La razón fundamental estriba, como se apuntó anteriormente, en la necesidad de evitar una desnaturalización de un gravamen puntual de devengo y liquidación inmediata, que sólo puede tener en cuenta aquellos gastos que revista un vínculo directo e indisoluble, esto es, gastos concretos y específicos en relación con el rendimiento obtenido en España y, en ningún caso, gastos globales de la actividad aseguradora. Lo contrario supondría imposibilitar la gestión del impuesto, al introducir en el tratamiento fiscal circunstancias no comprobables por la Administración Tributaria al derivar de hechos acaecidos en el Estado de residencia, obligando a tomar en consideración la situación global de la entidad en el país de residenciar, situación que no será fijada hasta pasados muchos meses después de liquidar el IRNR.

En segundo lugar, la dotación de la provisión prevista en el artículo 37 ROSSP, esto es, que se dote de forma individual, determinando su reparto entre los distintos tipos de pólizas y el cálculo anual de la misma informando sobre la dotación y desdotación de la misma.

En tercer lugar, identificar en base al libro o registro de inversiones qué concretas inversiones en entidades españolas se encuentran vinculadas a dichas pólizas unit linked, esto es, resulta indispensable probar que existe una relación directa e inmediata entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretende deducirse de dichos rendimientos».

No resulta suficiente, a juicio del TEAC, el informe pericial para acreditar la naturaleza de los contratos de seguro, porque se trata de dos informes genéricos, en los que no existe referencia a la actividad desarrollada por la entidad reclamante, ni al tipo de contratos de seguro formalizados por la misma. Los suplementos adjuntos a tales informes, con datos numéricos referidos a los periodos controvertidos, no permiten acreditar una vinculación directa entre los dividendos percibidos por la entidad y la provisión técnica dotada -prosigue el TEAC-, pues la entidad desarrolla distintos tipos de actividad dotando, para cubrir las obligaciones que deriven de las mismas, provisiones técnicas de distinta naturaleza. Por ello, ante la falta de especificidad de los informes aportados, la ausencia de prueba adicional suministrada por la entidad reclamante, la necesidad de que la Administración tomé en consideración magnitudes distintas de los gastos específicos y directos

directamente relacionados con el dividendo obtenido en territorio español y la omisión de referencia alguna respecto de la naturaleza de las pólizas suscritas en las alegaciones efectuadas por la reclamante no se puede considerar acreditado, en ningún caso, que se trate de seguros *unit linked* para cuya cobertura se habría dotado la provisión del artículo 37 del ROSSP. En consecuencia -concluye el TEAC- no se puede considerar que la provisión dotada tenga «...un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España», al no poder constatar la existencia de una relación directa entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretende deducirse de dichos rendimientos, lo que le lleva a confirmar el criterio aplicado por la Oficina Gestora, denegando la devolución de las cuantías solicitadas.

TERCERO.- La sentencia de instancia.

Por la representación procesal de R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado en el Registro General de la Audiencia Nacional el 16 de diciembre de 2019, contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 8 de octubre de 2019.

En los fundamentos de derecho 4 a 6 de la sentencia ahora recurrida se declara:

«4 (...) la Sala viene manteniendo que resulta contrario al Derecho de la UE no permitir la deducción de los gastos a la hora de determinar la base imponible; y así lo ha venido también a entender el propio legislador que permite la deducción de los gastos de las personas jurídicas no residentes sin establecimiento permanente, siempre que exista vinculación directa entre los ingresos obtenidos en España y tales gastos. En este sentido hemos declarado en la SAN de 5 de mayo de 2023 (FJ SEGUNDO):

"Por todas estas razones, en nuestras SAN (2ª) (dos) de 31 de marzo de 2023 (Rec. 736/2019 y 776/2019), en coherencia con el criterio que hemos venido manteniendo, hemos afirmado que admitida por el TS "la deducibilidad de las provisiones anudadas a las pólizas "unit linked",..... no encontramos razón para no aceptar la deducibilidad de las provisiones de las pólizas "no unit linked", si esa posibilidad existe en el ordenamiento español en el Impuesto de Sociedades para las aseguradoras residentes en España, porque, de ser así, se estaría dando un trato diferenciado a situaciones indiferenciadas, contrario al principio de la no discriminación y a la libre circulación de capitales. Obviamente siempre que se acredite la misma vinculación económica directa e indisociable con la actividad realizada en España, es decir, la obtención de dividendos". Como de hecho, salvo error de lectura, ya hicimos en nuestra SAN (2ª) de 20 de septiembre de 2018 (Rec. 174/2015). "

5.Y, en la misma sentencia (FJ TERCERO) después de analizar el significado de las provisiones técnicas en el ámbito del contrato de seguro y su tratamiento fiscal como "gasto deducible", examinamos la cuestión esencial - idéntica, como decíamos, a la que ahora debemos resolver - rechazando los argumentos dados por el TEAC (a los que se remite el Abogado del Estado en su contestación a la demanda) en los siguientes términos:

"Una vez que hemos llegado a la conclusión de que las provisiones son un "gasto" que debe ser tenido en cuenta debemos proceder al examen de lo que, en nuestra opinión, es la cuestión esencial que debe ser objeto de debate. En efecto, en lo esencial esto no es discutido por la demandante, solo podrán deducirse los gastos o si se quiere las provisiones que "están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España".

Al analizar este punto el TEAC sostiene que solo deben tenerse en cuenta los gastos vinculados con "la concreta actividad realizada en el país de la fuente". Rechazando -pp. 14 y ss- el juego de las provisiones del art 38 del RD 2486/1998 .

Razona que, por una parte, la actividad "realizada en España" no es la actividad aseguradora sino, tan solo, una concreta inversión financiera, una colocación de capital. En nuestra opinión este argumento no puede acogerse. Lo que en TEAC denomina una "mera colocación de capital" es parte sustancial de la actividad aseguradora que debe realizar actividades de inversión. De hecho, la normativa sobre Ordenación y supervisión de seguros controla la inversión de las entidades aseguradoras. No cabe por ello afirmar que la inversión en determinados activos no constituye una actividad económica realizada en España. Lo que se recoge en los informes aportados - pp.17 y ss. de la Resolución del TEAC- donde se explican las características de los contratos de seguros suscritos, los tomadores y la "forma de determinación del beneficio y la imposición sobre el mismo en base a lo dispuesto en la legislación alemana" y donde puede verse que realiza actividades unit likend y no unit linked, como por lo demás se reconoce en las pp. 6 y 16 de la demanda.

Por otra parte, esta forma de razonar viene a constreñir prácticamente la actividad aseguradora a la asunción de primar a cambio de asumir riesgos, pero al margen de que como hemos razonado que esto no es así, lo anterior se compadece mal con el criterio sostenido en le STS de 5 de junio de 2018 (Rec. 634/2017), que en un supuesto de retención de dividendos -no de actividad aseguradora en los términos restrictivos utilizados por el TEAC- entendió que si procedía deducir los gastos.

Debemos pues analizar el segundo argumento. Sin duda más complejo.

En esencia, lo que viene a sostener el TEAC es que frente a lo que ocurre en las provisiones técnicas de los seguros unit linked, en otros seguros, "no hay manera de conocer si los concretos dividendos obtenidos en España tienen relación con las pólizas que obligan a retornar los beneficios a los tomadores, o con otro tipo de pólizas...y en qué cuantía". Se trata de provisiones, se razona, "no concretos del específico rendimiento obtenido en España", por lo que es mejor que su deducibilidad, la cual no se niega, "se haga en el territorio de residencia que es donde la totalidad de circunstancias de la entidad puede conocerse, controlarse y tener el adecuado trato fiscal". Y concluye que la negativa a la deducción no se debe a la falta de reconocimiento de que, en efecto, la provisión técnica es deducible, sino a la "falta adecuada de prueba de los mismos". Admitir la posibilidad de deducción de las provisiones técnicas de participación en beneficios haría que el impuesto fuese de "muy compleja gestión, al exigir tener en cuenta en el estado de la fuente la situación global de la entidad en el país de residencia, situación que no será fijada hasta muchos meses después de liquidar el impuesto".

En resumen, el TEAC termina por admitir, quizás desdiciéndose de sus argumentaciones, que las provisiones técnicas reguladas en el art 37 del RD 2486/1998, es decir, las provisiones de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión, si serían deducibles. Y lo hace por entender, lo cual es cierto, que, conforme se infiere del art. 37, en las provisiones vinculadas a los seguros unit linked, el riesgo de la inversión es soportado "íntegramente por el tomador" y "se determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia para determinar el valor numérico de dichos derechos". Lo que supone que resulta posible verificar la conexión, pues en esta provisión "la dotación se hace en función de los riesgos de activos específicamente afectos, por lo que cabe establecer una relación directa entre la evolución de dichos activosy el importe que debe dotarse por dicha provisión para hacer frente a las obligaciones asumidas por la entidad con dichos tomadores o asegurados por el riesgo de inversión asumido por los mismos".

En el fondo, por lo tanto, como señala el TEAC se trata de un problema de dificultad en la gestión, pues la vinculación directa es relativamente sencilla de determinar en los casos de las provisiones relativas a los seguros unit linked, pero no lo es respecto de otras provisiones. (...)

Ahora bien, como hemos razonado en la SAN (2ª) de 31 de marzo de 2023 (Rec.736/2019), "los problemas operativos [o de prueba] que justificaron la denegación del TEAC....no pueden condicionar una respuesta equivalente entre las aseguradoras residentes y no residentes". Dicho de otro modo, la complejidad en la gestión no puede justificar la discriminación."

6. Llegados a este punto y considerando que la cuestión a resolver queda centrada en un tema de prueba (acreditación del "vínculo económico directo e indisociable") resulta cuestionable el proceder de la Administración desde el punto de vista del principio de buena Administración cuando, como también es el caso, el TEAC califica de insuficiente la prueba aportada, sin indicar cuál sería la prueba suficiente o los estándares de prueba que el obligado tributario debería cumplir para obtener la devolución instada, concluíamos, como también hicimos en nuestras SSAN de 31 de marzo de 2023 (R. 736/2019 y 776/2019) lo siguiente: (...)

"Esta forma de razonar tiene reflejo en la doctrina del TS. En efecto, la doctrina más reciente el Alto Tribunal - STS de 10 de enero de 2023 (Rec. 7260/2021 - afirma que "la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos de comparabilidad establecidos", corresponde, nadie lo duda, a la recurrente. Pero añade el Tribunal que "en ausencia de normativa nacional española que determine los concretos medios de prueba que debe aportar, no pueden ser requeridos medios de prueba que sean absolutamente conformes con lo que se exigirían...en España o que resulten desproporcionados o extraordinariamente difíciles de conseguir". Y añade algo que nos parece de especial relevancia, cuando se haya realizado un esfuerzo razonable por la recurrente y se dude "motivadamente del satisfactorio grado de acreditación, deberá utilizar activamente las facultades de obtención de información de que disponga en virtud del Convenio sobre Doble Imposición....La falta justificada de utilización de estos mecanismos de intercambio de información disponibles para la Administración debe valorarse en la distribución de la carga de la prueba y, en su caso, permitirá que se considere suficiente la aportada de forma seria y rigurosa por...el no residente para acreditar todos y cada uno de los elementos de la comparabilidad". (...)

Aplicando los anteriores criterios hemos razonado en nuestras SAN (2ª) (dos) de 31 de marzo de 2023 (Rec. 736/2019 y 776/2019), en efecto, frente a la alegación de imposibilidad o insuficiencia probatoria, la recurrente explica que "existe un registro que permite verificar la trazabilidad entre la rentabilidad de los activos en que se materializan las inversiones y la atribución de beneficios que contractualmente la compañía debe reconocer a los asegurados; existe concreción del modo del cálculo por el que debe dotarse anualmente la provisión.....; es irrelevante si la dotación a la provisión se realiza de forma global o individualizada por países y jurisdicciones, porque esta irrelevancia es igualmente aplicable a las residentes en España al aplicar la deducibilidad en el IS; y esta dificultad debería quedar superada dada la trazabilidad y vinculación directa entre cada inversión en acciones de empresas españolas, los dividendos obtenidos en cada una de ellas y la clase de póliza a la

que corresponde, y las reglas de cálculo mencionadas. Y más irrelevante aún, si cabe, es la posibilidad de que, admitiendo la deducibilidad de estas provisiones para los no residentes, se produzcan desdotaciones, porque para ello están las facultades de comprobación e inspección de la AEAT; pero nunca puede constituir un obstáculo al ejercicio de un derecho la posibilidad de que se ejercite desviadamente".

Pues bien, a igual conclusión llegamos aquí, a la vista del acopio de pruebas que en su día aportó ante la AEAT la hoy recurrente; en concreto los siguientes documentos:

- Modelos 210 presentados.
- Certificados de retenciones del banco custodio (DZ BANK) y del banco subcustodio (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.).
- Certificado de residencia en Alemania.
- Contrato de custodia con el banco.
- Copia traducida de los estatutos de la entidad reclamante (R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG) aprobados el 19 de noviembre de 2012. - Copia traducida de las cuentas anuales de la entidad R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en relación con los períodos controvertidos.
- Cuadro resumen, elaborado por la reclamante, con información relativa a los dividendos, fecha de pago, cuantía retenida y cuantía reclamada, entre otros datos.

En definitiva, que la recurrente ha justificado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 105 de la LGT, la vinculación exigible entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretende deducirse. De ahí la procedencia de la estimación del recurso y, consecuente declaración del derecho a obtener la devolución instada en los términos contenidos en el suplico de la demanda, incluidos los intereses de demora - STS de 5 de junio de 2018 (R.C. 634/2017).»

CUARTO.- Tramitación del recurso de casación

1.- Preparación.La abogacía del Estado presentó escrito, el 18 de julio de 2023, preparando recurso de casación contra la sentencia dictada.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos de plazo, legitimación y recurribilidad de la sentencia, el escrito de preparación identifica como infringidos el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR), en relación con el artículo 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP). También considera vulnerada la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - TJUE- de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608).

La sala juzgadora tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 21 de julio de 2023.

2.- Admisión.La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 29 de mayo de 2024, en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:

«Determinar si las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solamente llevan a cabo en España inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, puede considerarse, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 del TRLIRNR, por remisión a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) pueden deducirse por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.»

3.- Interposición.El abogado del Estado, en la representación que le es propia de la Administración General del Estado, interpuso recurso de casación mediante escrito de 15 de enero de 2025.

Concluye el escrito de interposición delimitando el objeto de su pretensión casacional en que esta Sala: «dicte sentencia por la que estime el recurso revocando la Sentencia recurrida en los aspectos y términos expresados.»

Considera que la cuestión con interés casacional debe responderse del modo siguiente:

«Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que no tienen en España establecimiento permanente ni actúan en régimen de libre prestación de servicios y solamente llevan a cabo en España la actividad de realizar inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario, no tienen, en aplicación del artículo 24.6 del TRLIRNR, el derecho a deducir de la base

imponible del IRNR los gastos relativos a las provisiones técnicas comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP, exclusivas de la actividad aseguradora, porque no están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España ni tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.»

Pretende que, sobre esta base, la sentencia de instancia sea casada y el recurso contencioso-administrativo sea, por tanto, íntegramente desestimado.

4.- Oposición al recurso interpuesto.El procurador, don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros en representación de la entidad R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG A.G., emplazada como parte recurrida en este recurso de casación, presentó escrito, el 2 de octubre de 2024, oponiéndose al presente recurso, en el cual, frente a las pretensiones del recurrente, tras la debida argumentación, concluye que: *«acuerde su desestimación, con imposición de las costas causadas a la parte recurrente, al amparo del artículo 93.4 LJCA.»*

5.- Votación, fallo y deliberación del recurso.De conformidad con el artículo 92.6 de la ley de la jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 7 de octubre de 2024, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Por providencia de fecha 19 de septiembre de 2025 se designó como magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 21 de octubre de 2025, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de casación.

El reconocimiento de la provisión técnica de participación en los beneficios como gasto deducible dentro del contexto particular del impuesto sobre la renta de los no residentes, constituye el objeto de este recurso, en tanto en cuanto, sobre la base imponible correspondiente a rentas que se obtengan sin mediación de establecimiento permanente por contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea se ha practicado la retención.

SEGUNDO. Posición de las partes.

Según la Abogacía del Estado la Sentencia infringe el art. 24.6 de la TRLIRNR, en relación con las normas europeas y españolas reguladoras de la actividad aseguradora y con el art. 38 del ROSSP, que regula la provisión de participación en beneficios y para extornos; esto, en interpretación concorde con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (" TJUE"), en particular la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608).

El art. 24 de la LIRNR tuvo una redacción original que fue reformada en lo aquí relevante por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que añadió un apartado 6 con la siguiente redacción:

«Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

2.ª (...)»

Admite la Abogacía del Estado que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. Es decir, según la Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los *«gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas»* sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 (Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que

se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias) el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.

Sostiene la Abogacía del Estado que la infracción del art. 24.6 TRLIRNR es doble. Supone que en éste la deducción de un gasto se condiciona a que se cumplan dos requisitos:

Que el gasto tenga "un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España".

Que el gasto esté "relacionado directamente con los rendimientos obtenidos en España".

Para la Abogacía del Estado son dos requisitos diferentes, de manera que puede que se dé uno, los dos o ninguno.

Rechaza que cuando se trata de una provisión asimilable a la de participación en beneficios o para extornos del art. 38 del ROSSP, se dan los dos requisitos, razonando del modo siguiente:

La dotación a la provisión técnica de participación en beneficios o para extornos del art. 38 del ROSSP -o una similar, equivalente o comparable, como hay que admitir que era el caso- es un gasto propio de la actividad aseguradora, realmente característico de ésta. De hecho, el art. 13.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, disponía que serán deducibles los «gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras.»

Como gasto deducible es consustancial que se realice por una entidad aseguradora.

La ley exige que el gasto tenga un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. La Abogacía del Estado no cuestiona que esa provisión tiene un vínculo de esa naturaleza con la actividad realizada por la Aseguradora en Alemania y, acaso, en otras jurisdicciones. Pero de lo que se trata es de que lo tenga con la actividad desarrollada en España.

Cree que la Sentencia yerra al considerar que la actividad desarrollada en España por la Aseguradora es una actividad aseguradora. Si no lo es, un gasto característico de las aseguradoras no puede tener el requerido vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España.

Rechaza que la mera inversión en activos financieros -que es la única actividad en España- pueda caracterizarse como actividad aseguradora. No solo porque es una actividad que, además de las aseguradoras, pueden desarrollar, y de hecho desarrollan, muchas otras personas o entidades. Para algunas es la actividad propia de su razón de ser, de su "objeto social" como personas jurídicas, empresas o sociedades mercantiles; en otras, es una actividad que desarrollan porque deciden hacerlo, a veces de manera sistemática, otras esporádica, pero que no puede confundirse con lo que en verdad es su actividad.

La actividad propia de las entidades aseguradoras es la que determinan y regulan la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (la "Directiva") y, en lo que respecta a los períodos concernidos, el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (la "LOSP") o, en cuanto al Derecho hoy vigente, la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Estas normas no definen "el seguro privado" (en terminología de la LOSP) ni la "actividad aseguradora y reaseguradora privada" (en terminología de la ley vigente) de manera que incluya como componente sustancial el desarrollo de la inversión en activos financieros. Es verdad que las entidades aseguradoras invierten en muy distintos activos, pero no es la inversión lo que las caracteriza y define. Esa inversión -respecto de las que las normas aplicables se limitan en esencia a proclamar y materializar el principio de prudencia-, por sí misma, no hace que una entidad sea aseguradora o desarrolle la actividad a la que se asocian las provisiones técnicas; ni es una actividad que estén legalmente obligadas a desarrollar.

Conviene estar -porque es de lo que se trata- al régimen jurídico vigente aplicable a un caso en el que una entidad aseguradora no residente en España, pero sí residente en otro Estado de la UE vaya a desarrollar en España la actividad aseguradora. Esto está regulado por la Directiva y por la ley española. Hay que tener en cuenta lo que disponía el art. 78 de la LOSP.

Las libertades comunitarias permiten que una aseguradora de un Estado miembro desarrolle su actividad en otro sin necesidad de ser residente en éste; puede hacerlo mediante una sucursal, pero ni siquiera es necesario

que establezca una sucursal, sino que puede actuar directamente desde su Estado de residencia: en esto consiste el "régimen de libre prestación de servicios".

Al respecto, son significativos para nuestros fines otros preceptos, como los arts. 85 y 86 de la LOSSP.

Sostiene la Abogacía del Estado que no hay duda de que la aseguradora no se sujetó a estas normas. Y no lo hizo porque ni pretendía operar en España, ni de hecho operó en España como tal entidad aseguradora. Solo pretendía invertir en acciones emitidas por sociedades españolas, para lo que no necesitaba sujetarse a régimen administrativo alguno aplicable al ejercicio en España de la actividad aseguradora.

Afirma que la aseguradora no desarrollaba en España la actividad aseguradora (a la que se asocia inexorablemente la deducibilidad de las provisiones técnicas). No lo hacía en ninguna de sus posibles modalidades, ni siquiera en régimen de libre prestación de servicios. Como no lo hacía, no necesitaba cumplir requisitos, seguir procedimientos ni someterse en modo alguno a las competencias de la Administración española. Para invertir en acciones de sociedades españolas y percibir dividendos no necesitaba hacer nada de esto, no le resultaba aplicable norma alguna, más allá de las normas alemanas a las que estarán sujetas sus inversiones (para verificar que son prudentes), cualquiera que sea el lugar en el que se hagan.

Sigue razonando la Abogacía del Estado que el precedente de la sentencia del TS de 5 de junio de 2018 (rec. cas. 634/2017) no avala la posición de la Sentencia. El supuesto de hecho enjuiciado tuvo lugar bajo la vigencia de la LIRNR en su redacción anterior a la reforma introducida por la Ley 2/2010, de 1 de marzo, período en el que se admitía la vulneración por la ley española del art. 63 del Tratado. Leemos en la sentencia *«que la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del art. 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo»*. Cabría añadir, que el caso versaba sobre contratos denominados "unit linked", *«caracterizados por una nota común: que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión»*, que no es el caso presente.

Con respecto a la relación directa de la provisión técnica con los rendimientos obtenidos en España, la Abogacía del Estado sostiene que de ningún modo la existencia de tal relación directa es "un problema de gestión y de prueba" (como interpreta la Sentencia). Es una cuestión jurídica, de interpretación de la norma -el art. 24.6 TRLIRNR- respecto del caso de la provisión técnica "de participación en beneficios y para extornos" del art. 38 del ROSSP, al que según parece se asimilan las provisiones alemanas que la Sentencia considera deducibles del IRNR.

Pues bien, no hay relación -menos aun directa- entre la dotación a la provisión y los dividendos percibidos de sociedades españolas. La inexistencia de una relación directa no se afirma sobre la base de concluir sobre los hechos mediante la valoración de pruebas sino sobre la del análisis conceptual de la provisión de que se trata, de su naturaleza.

En todo caso, la cuestión -es importante notarlo- no es si hay o no alguna relación sino si esa hipotética relación es directa. Pues si hubiera una relación, pero no directa, entonces la recta aplicación del art. 24.6 TRLIRNR proscibiría la deducción de la provisión. Cree que la sentencia de instancia pasa por alto la naturaleza directa que necesita tener la relación entre el gasto que se quiere deducir y los dividendos. Si la relación, aun existiendo, es indirecta, mediata, no biunívoca, entonces no procede la deducción.

El gasto aquí en cuestión es una provisión técnica comparable a la provisión de participación en beneficios y para extornos, del art. 38 del ROSSP.

El vínculo no se establece entre la provisión (cuya dotación es deducible) y tales o cuales rentas (las rentas, ingresos o inversiones no se toman en consideración para nada: no guardan relación con esta provisión) sino entre la provisión y la evolución del riesgo. En efecto, algunos contratos de seguro contemplan el derecho a recuperar parte de la prima satisfecha si al cabo de determinado período, por ejemplo el periodo del seguro, se ha producido un superávit de la cuenta de resultados de la póliza; o, en otras palabras, si la siniestralidad ha resultado favorable.

La ausencia de toda relación directa entre este tipo de provisiones y los dividendos se comprende todavía mejor, si cabe, contrastándolo con la llamada "Provisión de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversión", a la que se refiere el artículo anterior, el 37, del ROSSP.

Son los llamados seguros "unit linked", en realidad una operación de inversión más que de seguro, si bien que se realiza por entidades aseguradoras bajo la veste formal del contrato de seguro. Las características son las contrarias:

No guarda relación con la evolución del riesgo.

Corresponde a contratos en que se ha "estipulado que el riesgo de inversión será soportado íntegramente por el tomador" (no es la entidad aseguradora, como es propio del genuino seguro, la que asume el riesgo de la ocurrencia de un siniestro).

Y la provisión (el gasto deducible) sí se "determinará en función de los activos específicamente afectos o de los índices o activos que se hayan fijado como referencia". De modo que entre los dividendos obtenidos por tales activos y la provisión sí hay una relación directa.

Para la Sentencia parece no haber diferencias relevantes entre las provisiones de los arts. 37 y 38 a los efectos que aquí importan. La diferencia resplandece, a juicio de la Abogacía del Estado, si se considera: Que el art. 37 expresamente excluye para el "cálculo de esta provisión las disposiciones establecidas en el artículo 33 de este Reglamento", es decir las reglas generales del cálculo de la provisión de seguros de vida.

La regulación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) [«Directiva 2009/138»] en su art. 132.3 dispone que:

«Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, en lo que atañe a los activos conexos a contratos de seguro de vida en los que el riesgo de inversión venga soportado por los tomadores, será de aplicación el presente apartado, párrafos segundo, tercero y cuarto.

Cuando las prestaciones estipuladas en un contrato estén directamente vinculadas al valor de las participaciones en un OICVM, según lo definido en la Directiva 85/611/CEE, o al valor de los activos contenidos en un fondo interno en posesión de la empresa de seguros, generalmente dividido en participaciones, las provisiones técnicas correspondientes a dichas prestaciones deberán estar representadas lo más estrechamente posible por dichas participaciones o, si estas no se hubieran determinado, por dichos activos.»

Es decir, se trata de un caso muy particular en el que cabe admitir (el TEAC lo reconoce) que se entabla una relación directa entre la provisión y los activos afectos (acaso, por ende, con los dividendos que devengan). Obviamente, una relación que no se da en absoluto en las demás provisiones técnicas, lo cual se aprecia perfectamente por contraste con las normas peculiares de ésta.

En definitiva, la Sentencia aprecia la existencia de una relación directa, entre la provisión por participación en beneficios o para extornos y los dividendos percibidos. Pero no existiendo tal relación, y menos directa, el gasto que representa su dotación, muy probablemente deducible en el Estado de residencia, no lo es en el IRNR. Al concluir lo contrario, la Sentencia, también en esto, vulnera el art. 24.6 de la TRLIRNR.

Dice la Abogacía del Estado que la jurisprudencia del TJUE lejos de avalar la conclusión de la Sentencia, milita a favor de su posición. Determinadas sentencias, como las de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688) y 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), no sirven de apoyo a la Sentencia porque versan sobre la tributación de fondos de pensiones (no de compañías aseguradoras). En realidad, servirían para sostener un trato similar a las aseguradoras respecto de la provisión de contratos "unit linked", precisamente porque en éstos la posición de aquellas es muy similar a la de quienes operan en gestión de inversiones, sin soportar el riesgo de éstas; pero no cuando se trata de genuinas operaciones de seguros (donde las provisiones técnicas no se vinculan con determinados ingresos).

Más utilidad tiene la Sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608) más exactamente los párrafos 58 y 59.

Por su parte, la parte recurrida comienza su escrito de oposición recordando que R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG es una entidad aseguradora residente en Alemania, autorizada por el organismo competente y cuyas actividades están dentro del ámbito de aplicación de la « Directiva 2009/138».

Mantiene la inexistencia de infracción por la Sentencia recurrida del artículo 26.4 TRLIRNR, en relación con las normas europeas y españolas reguladoras de la actividad aseguradora y, en particular, con el art 38 ROSSP, en interpretación concorde con la doctrina del TJUE, en particular con la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608).

Las entidades aseguradoras pertenecientes a la Unión Europea tienen un régimen armonizado en materia de provisiones técnicas y la finalidad de todas las provisiones técnicas es garantizar la solvencia estática y dinámica de las entidades aseguradoras.

Tanto el art. 14.7 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, como el art. 13.4 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, otorgan la calificación de gasto fiscalmente deducible para la determinación de la

base imponible de este impuesto, al que están sometidas las entidades aseguradoras con residencia fiscal en España, a los gastos relativos a las provisiones técnicas, sin distinción entre ellas, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables.

El acervo de la Unión Europea exige no discriminar a las entidades aseguradoras de otros Estados miembros sin residencia fiscal en territorio español, incluso si carecen de establecimiento permanente en España, lo que explica que el art. 26.4 TRLIRNR les permita considerar como gastos fiscalmente deducibles para determinar la base imponible en el IRNR correspondiente a las rentas obtenidas en territorio español todos los gastos fiscalmente deducibles para determinar la base imponible en el IS, *«siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España»*.

Sostiene que es indiscutible que esas dos condiciones a las que el precepto legal interno supedita la deducibilidad de los gastos no pueden ser interpretadas de tal modo que consientan la discriminación entre entidades aseguradoras con residencia fiscal en España y las entidades aseguradoras con residencia fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea, como igualmente es indudable que su exégesis no puede comportar una vulneración, ni directa ni indirecta, de la libre circulación de capitales reconocida en el art. 63.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [«TFUE»].

Defiende que si una entidad aseguradora con residencia fiscal en España puede invertir en sociedades cotizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que no esté establecida y, por ende, percibir dividendos, sin que nadie le discuta la deducibilidad como gasto fiscal de las provisiones técnicas que haya dotado en la cuantía mínima exigida por las normas sectoriales aplicables, a efectos del cálculo de la base imponible del IS, ocasiona un trato discriminatorio que vulnera la libre circulación de capitales, a juicio de la parte recurrida, que cuando la misma actividad inversora se realiza en España por una entidad aseguradora no establecida residente fiscal en otro Estado miembro de la Unión Europea se niegue la deducibilidad fiscal de las provisiones técnicas comparables a los efectos del cálculo de la base imponible del IRNR.

Los eventuales problemas de gestión y control del IRNR que ocasione el resultado hermenéutico que defiende y la Sala a *quor*atifica en su sentencia no constituyen un óbice atendible, conforme al acervo de la Unión Europea y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo de la que la sentencia recurrida da cumplida cuenta.

A continuación, procede a rebatir los tres argumentos que esgrime el Abogado del Estado para fundamentar la infracción que imputa a la sentencia recurrida.

El primero de ellos es que el Abogado del Estado viene a sostener que la entidad aseguradora sólo tendría derecho a la deducibilidad fiscal como gasto de las provisiones técnicas discutidas si hubiera operado en España como una entidad aseguradora y, por tanto, hubiera realizado una actividad aseguradora, en vez de limitarse a efectuar una concreta inversión financiera, una colocación de capital.

Según la parte recurrente, esta disociación entre las actividades propias de una entidad de seguros, en actividades aseguradoras y en actividades inversoras, no se realiza cuando la entidad aseguradora tiene su residencia fiscal en España y percibe dividendos de sociedades cotizadas residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que no esté establecida, a la hora de determinar la deducibilidad fiscal en la base imponible del IS de las provisiones técnicas que haya dotado, lo que resulta suficiente para rechazarla, pero es que además, como certeramente defiende la Sala a *quo*en la Sentencia recurrida, una entidad aseguradora debe realizar actividades de inversión, como parte de su actividad económica y como exigencia de los contratos de seguros suscritos, inversiones que son sometidas a supervisión para confirmar que son prudentes, y eso fue lo que hizo la entidad recurrente en territorio español en los años 2011 a 2013, en los que realizó actividades *unit linked* y no *unit linked*, como expresamente reconoce la Sala sentenciadora.

Dice la recurrente que esa forma de razonar del Abogado del Estado, que constriñe prácticamente la actividad aseguradora a la asunción de prima a cambio de asumir riesgos, resulta equivocada, porque si se entendiera de ese modo, carecería de sentido que la «Directiva 2009/138» dedique dentro de su Título I, rotulado como *«Disposiciones generales sobre el acceso a la actividad de seguro directo y de reaseguro y su ejercicio»*, un Capítulo VI, titulado *«Normas relativas a la valoración de activos y pasivos, las provisiones técnicas, los fondos propios, el capital de solvencia obligatorio, el capital mínimo obligatorio y las inversiones»*, incluyendo en su seno una Sección 2 para regular las provisiones técnicas y una Sección 6 para regular las inversiones de las entidades de seguros y reaseguros (cfr., en particular, el art. 133). Luego, en el acervo de la Unión Europea tan propias de la actividad aseguradora son la dotación de provisiones técnicas como la realización de inversiones. En este sentido se ha de tener presente que el art. 18 de la misma «Directiva 2009/138», al regular las condiciones de autorización de una compañía de seguros, alude a *«las operaciones que se deriven directamente»* de la actividad aseguradora [apartado 1.a)], entre, como se obtiene de la citada Sección 6, se encuentran propias de la inversión financiera.

En este sentido, la propia « Directiva 2009/138» dice que las entidades aseguradoras tienen objeto social limitado a la realización de operaciones de seguros, siendo su actividad inversora instrumental del negocio asegurador

Rebate la tesis del Abogado del Estado que descarta que la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2018 (rec. cas. 634/2017) avale la posición de la Sentencia recurrida, reconociendo que esa sentencia se refiere a ejercicios anteriores a la entrada en vigor de la reforma que menciona del art. 24.6 TRLIRNR e igualmente lo es que la reforma se produjo por considerar que la regulación previa vulneraba el art. 63 TFUE, pero defiende que no es imposible que la interpretación y, en particular, la aplicación de la redacción posterior de este precepto legal no pueda vulnerar el art. 63 TFUE, en contra de lo que parece dar a entender el abogado del Estado. Aún más, considera que si el artículo 26.4 TRLIRNR se interpreta y aplica como asegura la Abogacía del Estado de la sostiene en su recurso de casación se produciría la vulneración del artículo 63 TFUE en casos como el litigioso.

Admite que el supuesto examinado por el Tribunal Supremo en la referida sentencia de 5 de junio de 2018 venía referido a seguros *unit linked*, pero también lo es que la Sala a quo admite que la parte recurrida realizó actividades *unit linked* y no *unit linked*, y no está de más subrayar que el Tribunal consideró en dicha sentencia que se producía una vulneración material del Derecho de la Unión Europea, «*porque las sociedades no residentes perceptoras de dividendos de empresas residentes son discriminatoriamente tratadas en relación con esas mismas empresas si fueran residentes, como consecuencia de que la base imponible del impuesto real se calcula en las primeras sobre el importe íntegro [...], sin posibilidad alguna de deducir los gastos o provisiones*».

La razón fundamental por la que el Abogado del Estado no acepta la deducibilidad fiscal de una provisión comparable con la del art. 38 ROSSP es que el vínculo no se establece entre la provisión y tales o cuales rentas, sino entre la provisión y la evolución del riesgo o, como afirma el TEAC, en el cálculo y dotación de dicha provisión, y, a diferencia de la prevista en el art. 37 ROSSP, no existe una relación entre el riesgo asumido por cada tomador y unos activos específicamente afectos al mismo, por lo que no se puede afirmar que los dividendos cobrados en territorio español hayan determinado, como sí sucede en la provisión del art. 37, una mayor dotación de la provisión del art. 38 que el reclamante pretende deducible.

El Abogado del Estado trata de demostrar que no basta la existencia de una relación entre los dividendos y la provisión del artículo 38 ROSSP, sino que se requiere la existencia de una relación directa que, a su juicio, está ausente.

La parte recurrida asegura que olvida una de las premisas de partida: la interpretación y aplicación del art. 24.6 TRLIRNR no puede dar lugar a un situación discriminatoria que vulnere la libre circulación de capitales reconocida en el art. 63 TFUE, porque es necesario reiterar, una vez más, que si la misma inversión y en las mismas condiciones que la realizada por R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en España la hubiera llevado a cabo en otro Estado miembro de la Unión Europea una entidad aseguradora con residencia fiscal en España nadie le habría negado la íntegra deducibilidad fiscal como gasto de la provisión del art. 38 ROSSP en la base imponible del IS.

En suma, si ambas provisiones técnicas, la del art. 37 ROSSP y la del art. 38 ROSSP, son con carácter general deducibles en el IS, se produce una discriminación contraria a la libre circulación de capitales si se niega la deducibilidad fiscal como gasto de cualquiera de ellas en el IRNR, cuando unas y otras (entidades aseguradoras con residencia fiscal -IS- y entidades aseguradoras sin residencia fiscal -IRNR-) obtienen beneficios (percepción de dividendos) como consecuencia de sus inversiones en sociedades cotizadas residentes en otro Estado miembro en el que no están establecidas.

Defiende, por último, que la jurisprudencia del TJUE avala la tesis que mantiene la Sala a quo en la Sentencia recurrida.

Reconoce que las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688) y 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), se refieren a fondos de pensiones y no a entidades de seguros, pero no está demás, dice, reproducir el fallo de la segunda de ellas: «*Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual los dividendos distribuidos por una sociedad residente a un fondo de pensiones residente, por una parte, están sometidos a una retención en origen que puede imputarse íntegramente al impuesto sobre sociedades de dicho fondo y dar lugar a una devolución cuando el impuesto percibido mediante retención en origen sea superior al impuesto sobre sociedades adeudado por el fondo y, por otra parte, no dan lugar a un incremento del resultado gravado por el impuesto sobre sociedades, o dan lugar únicamente a un incremento mínimo de este, debido a la facultad de deducir de dicho resultado las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones, mientras que los dividendos abonados a los fondos de pensiones no residentes están sujetos a una retención en origen que constituye, para estos, un gravamen definitivo, cuando*

el fondo de pensiones no residente destina los dividendos percibidos a la provisión de las pensiones que deberá abonar en el futuro, extremo que corresponde verificar al tribunal remitente».

Razona que si sustituimos fondos de pensiones por entidades de seguros y provisiones para hacer frente a los compromisos por pensiones por provisiones técnicas de entidades de seguros, la conformidad con el Derecho de la Unión Europea de la tesis que sostiene la Sala a quo en la Sentencia impugnada parece evidente, sin que sea contradicha por la doctrina sentada en los apartados 58 y 59 de la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, porque la comparabilidad debe hacerse en este caso con el tratamiento fiscal como gasto de las provisiones de los artículos 37 y 38 ROSSP a la hora de determinar la base imponible del IS de una entidad aseguradora residente fiscal en España que perciba dividendos de sociedades residentes en otro Estado miembro en el que no esté establecida.

Por último, en el hipotético supuesto de que este Tribunal tuviera dudas sobre la aplicabilidad de la doctrina sentada en las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia (C-342/10, EU:C:2012:688) y 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), para resolver este litigio, porque dichas sentencias no se refieren a entidades aseguradoras sino a fondos de pensiones, señala que este Tribunal podría plantear cuestión prejudicial de interpretación al TJUE para despejarlas, al amparo del artículo 267 TFUE.

TERCERO.- El criterio de la Sala.

Es necesario interpretar el artículo 24 TRLIRN, relativo a la base imponible en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, que en su redacción aplicable disponía que:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España [...].»

Dicho precepto fue modificado por el artículo 2.5 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, pasando a tener el siguiente contenido:

«6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir:

[...] b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal».

Según se señala en su Preámbulo, la reforma obedeció a dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión Europea, a cuyo fin se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente.

En ese punto conviene recordar que, en su escrito de interposición, la Abogacía del Estado manifiesta que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. Es decir, según la propia Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los "gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible.

Por su parte, el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y también el artículo 14.7 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, otorgan la calificación de gasto fiscalmente deducible para la determinación de la base imponible de este impuesto, al que están sometidas las entidades aseguradoras con residencia fiscal en España, a los gastos relativos a las provisiones técnicas, sin distinción entre ellas, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables.

La redacción de ambos es la misma. Concretamente es la siguiente: *«los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se produzca.*

Las correcciones por deterioro de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.».

Por su parte, el artículo 29 (Concepto y enumeración de las provisiones técnicas) del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), en la redacción a la sazón vigente, establece:

«1. Las provisiones técnicas deberán reflejar en el balance de las entidades aseguradoras el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. Se deberán constituir y mantener por un importe suficiente para garantizar, atendiendo a criterios prudentes y razonables, todas las obligaciones derivadas de los referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la entidad aseguradora frente a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad o frente a posibles riesgos especiales. La corrección en la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, serán certificadas por un Actuario de Seguros, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad aseguradora.

En el caso de que se elaboren balances con periodicidad diferente a la anual, el cálculo y la constitución de las provisiones técnicas se efectuarán aplicando los criterios establecidos en este Reglamento con la adaptación temporal necesaria.

2. Las provisiones técnicas son las siguientes:

- a) De primas no consumidas.*
- b) De riesgos en curso.*
- c) De seguros de vida.*
- d) De participación en beneficios y para extornos.*
- e) De prestaciones.*
- f) La reserva de estabilización.*
- g) Del seguro de decesos.*
- h) Del seguro de enfermedad.*
- i) De desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo.*

3. Las provisiones técnicas aplicables al reaseguro aceptado y cedido serán las recogidas en los párrafos a) a e), ambas inclusive, del apartado anterior, exceptuando, en cuanto al cedido, la contemplada en el párrafo b). Igualmente será aplicable la provisión contemplada en el párrafo f) anterior para las aceptaciones en reaseguro de riesgos catastróficos.

El importe correspondiente a las provisiones técnicas del reaseguro aceptado y cedido deberá calcularse en la forma prevista en este Reglamento, teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones específicas de los contratos de reaseguro suscritos.

El cálculo de las provisiones por operaciones de reaseguro aceptado, tomará como base los datos que facilite la entidad cedente, incrementándolos en cuanto proceda de acuerdo con la experiencia de la propia entidad.

4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberán constituir provisiones técnicas, incluida la reserva de estabilización, suficientes para el conjunto de sus actividades.».

El propio RTEAC entendió que la aseguradora pretendía la deducción de la dotación a una provisión que, con independencia de su denominación y régimen en Alemania, resulta equivalente a una de las provisiones técnicas reguladas en el Derecho español aplicable a las entidades aseguradoras residentes, la "provisión de participación en beneficios y para extornos", incluida en la enumeración del art. 29.2 regulada en el art. 38, ambos del ROSSP.

También es necesario interpretar el art. 38 ROSSP, referente a la provisión de participación en beneficios y para extornos, que determina que:

«1. Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos.

2. Los seguros distintos del seguro de vida que garanticen el reembolso de primas bajo determinadas condiciones o prestaciones asimilables incluirán en esta provisión las obligaciones correspondientes a dicha garantía, calculadas conforme a las siguientes normas:

Se incluirán en la provisión todas las obligaciones por los contratos que sobre la base de la información existente al cierre del ejercicio sean susceptibles de dar lugar a las prestaciones citadas.

La provisión a dotar comprenderá el importe de las primas a reembolsar o prestaciones a satisfacer imputables al período o períodos del contrato ya transcurridos en el momento de cierre del ejercicio».

En sus alegaciones casacionales las partes cuestionan la interpretación de la normativa española aplicable a tenor de la jurisprudencia sentada por el TJUE.

La sentencia de dicho TJUE de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), resulta del máximo interés. En ella, se contienen referencias a doctrina consolidada del propio Tribunal que permiten conocer su visión jurisprudencial.

Comenzaremos reproduciendo dos de sus apartados:

«28. De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencias de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, apartado 48, y de 29 de julio de 2024, *Keva y otros*, C-39/23, EU:C:2024:648, apartado 40 y jurisprudencia citada).

31. Cuando un Estado miembro practica una retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en ese Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a efectos de determinar si una legislación de dicho Estado miembro es compatible con el artículo 63 TFUE, apartado 1, corresponde al órgano jurisdiccional nacional de que se trate, único que puede examinar los hechos del litigio del que está conociendo, verificar si la aplicación de una retención en la fuente a los dividendos distribuidos a una sociedad no residente tiene como resultado, en definitiva, que dicha sociedad soporte una carga impositiva mayor, en el mismo Estado miembro, que la que soportan los residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, apartado 48). »

También nos importan determinados apartados de la sentencia de 20 de junio de 2024, Faurécia (C-420/23, EU:C:2024:534) que sintetizan, en parte, la jurisprudencia sobre el marco jurídico originario de la libertad de circulación, concretamente, los siguientes:

«21 El artículo 63 TFUE , apartado 1, prohíbe con carácter general las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros. Las medidas prohibidas por esa disposición, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencia de 27 de abril de 2023, L Fund, C-537/20 , EU:C:2023:339, apartado 42 y jurisprudencia citada).

28.No obstante, con arreglo al artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), lo dispuesto en el artículo 63 TFUE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital.

29 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en que residan o del Estado miembro en el que inviertan sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22 , EU:C:2023:880, apartado 27 y jurisprudencia citada].

30 En efecto, las diferencias de trato permitidas por el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), no deben constituir, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo, ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22 , EU:C:2023:880, apartado 28 y jurisprudencia citada]. »

Igualmente, resulte de interés los apartados 48 y 49 de la sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en tanto en cuanto se refirieren al requisito de la vinculación entre el gasto, pretendidamente deducible, y la actividad realizada. En ellos se declara:

«48 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imponibles en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünwald, C-559/13 , EU:C:2015:109, apartado 29; de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartado 37; de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 57, y de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17 , EU:C:2019:960, apartado 74).

49 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, presentan un vínculo directo con la actividad considerada los gastos ocasionados por esta y necesarios por tanto para su ejercicio (sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünwald, C-559/13 , EU:C:2015:109, apartado 30 y jurisprudencia citada; de 13 de julio de 2016, Brisal y KBC Finance Ireland, C-18/15 , EU:C:2016:549 , apartado 46, y de 6 de diciembre de 2018, Montag, C-480/17 , EU:C:2018:987, apartado 33).»

En principio, las provisiones técnicas no parecen poder relacionarse con la percepción, en sí misma, de los dividendos. En términos semejantes a esta cuestión ya se ha planteado otra que ha sido abordada en la citada sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en relación con la posibilidad de deducir de su beneficio imponible relativo a los dividendos las cargas correspondientes a sus clientes en el marco de contratos de seguro "en unidades de cuenta".

En dicha sentencia, apartados 54 a 57, se declara:

«54 En efecto, en los apartados 55 y 81 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17 , EU:C:2019:960), posterior a la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que un fondo de pensiones no residente que destine los dividendos percibidos a dotar provisiones por las pensiones que deberá abonar en el futuro, ya sea deliberadamente o de conformidad con la normativa vigente en su Estado de residencia, se encuentra en una situación comparable a la de un fondo de pensiones residente en relación con una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular el impuesto sobre sociedades, la percepción de dividendos por ese fondo de pensiones residente da lugar a un incremento del resultado sujeto a tributación muy reducido, e incluso, en algunos casos, inexistente. Efectivamente, el Tribunal de Justicia señaló, en el

mencionado apartado 55, que tal percepción conlleva un incremento proporcional de las provisiones técnicas y que únicamente se produce un incremento del resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones residente cuando los rendimientos de las inversiones extracontables no se trasladen al crédito de los distintos contratos de este último fondo de pensiones.

55 En los apartados 79 y 80 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), el Tribunal de Justicia consideró, en efecto, por una parte, que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia existía una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente y, por otra parte, que tal normativa nacional, que permitía la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes, facilitaba así la acumulación de capitales de tales fondos, mientras que todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

56 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que las obligaciones de los fondos de pensiones relativas a la inversión de las primas de seguro y a la afectación de los dividendos percibidos para provisionar las pensiones de jubilación pueden fundamentar la comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes y no residentes a la luz de una normativa nacional que, mediante las modalidades de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, permita eximir total o casi totalmente los dividendos percibidos por un fondo de pensiones residente, cuando exista una relación de causalidad entre la percepción de los dividendos y las cargas constituidas por dichas obligaciones y derivadas de la actividad de tales fondos.

57 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien una sociedad como XX no constituye un fondo de pensiones, la actividad de esta se caracteriza por el hecho de que dicha sociedad invierte, en particular en acciones en los Países Bajos, para cubrir sus compromisos frente a sus clientes en el marco de contratos en unidades de cuenta y que los rendimientos obtenidos de la inversión por dicha sociedad conllevan la correspondiente modificación del valor de sus compromisos frente a los clientes en virtud de los contratos mencionados.»

No cabe duda de la utilidad de las consideraciones que acabamos de reproducir. La intercambialidad de tales argumentos entre los fondos de pensiones y las compañías aseguradores, a los presentes efectos, resulta viable.

La representación procesal de la Administración estatal no ha puntualizado qué objetivo persigue la deducción de las provisiones, pero está claro que se pretende, en última instancia, mantener la solvencia de las entidades. El único criterio de distinción entre residentes y no residentes en la normativa nacional se basa, realmente, en el lugar de residencia de la aseguradora.

La libre circulación de capitales se opone a una normativa nacional que tome en cuenta los rendimientos brutos de los no residentes sin deducir las provisiones técnicas, mientras que los residentes tributan por rendimientos netos previa deducción de los gastos de las provisiones técnicas.

El auto de admisión establece la relevancia casacional en torno al art. 24.6 del TRLIRNR. Ambas partes procesales parten del presupuesto de que los dividendos repartidos por una entidad residente en España se consideran rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas y, por ello, sometidas a tributación en España, en manos de las entidades no residentes que operen en nuestro país sin mediación de un establecimiento permanente. Dicho de otra forma, están sujetas ex artículo 15, siendo un supuesto de renta obtenida en España (actual artículo 13.1.f).

Las provisiones técnicas son gastos y como tales deducibles a efectos del impuesto de sociedades (art. 13 TRLIS y 14.7 LIS), siempre que hayan sido dotadas conforme a los criterios del citado Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo artículo 38 se recoge expresamente la provisión de participación en beneficios y para extornos. Dentro de este contexto normativo, cabe interpretar el artículo 24.6 del TRLIRNR y su aplicación a una provisión de semejante naturaleza.

La Abogacía del Estado considera que este tipo de provisiones técnicas en el ramo de seguros no equivalen al desarrollo de actividad aseguradora, más bien, a su juicio, estamos en presencia de una mera colocación de capital, sin embargo, ello se compadece mal con el actual sistema de seguros amparado por la normativa española, particularmente, el art. 29 ROSSP, reproducido anteriormente.

El funcionamiento general de las pólizas "unit linked" y las pólizas con participación en beneficios "no unit linked" resulta muy similar, a los efectos que ahora importan, dado que en ambos tipos existe un traslado económico de la rentabilidad producida por los dividendos a los tomadores de las pólizas, ya sea por soportar el

tomador el riesgo económico de las inversiones (pólizas "unit linked"), o por haber acordado con los tomadores el traslado a ellos de una parte de la rentabilidad de los activos afectos a la póliza ("with profits").

Una provisión técnica de participación en beneficios, no cabe caracterizarla como ajena al proceso productivo del sector asegurador, donde la solvencia resulta capital. Así lo expresa la propia ley del sector, hoy vigente, Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. cuando manifiesta en su preámbulo:

«La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras puedan operar en un único mercado interior.

La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente. El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades, en consonancia con los desarrollos alcanzados en materia de gestión de riesgos y con la evolución reciente en otros sectores financieros. Se adopta así para el sector asegurador europeo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas específicas sobre el capital económico. El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objetivo de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. El tercero se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos clave de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión.

Adicionalmente a la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo y de los cambios que ello requiere en la forma de gestión de las entidades y en la actuación de las autoridades supervisoras, la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de automóviles, incorporando los contenidos recogidos en las directivas que ya se habían transpuesto en su momento al Derecho español de seguros, como por ejemplo, la Directiva 2001/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros.

El esquema ha sido completado con los desarrollos normativos y la medidas de ejecución derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo en la Unión Europea por el establecimiento de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, mediante el Reglamento (CE) n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión y ordenación de seguros y reaseguros, logrando una mayor armonización reguladora y una mejor coordinación internacional e intersectorial.

Las disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento que la desarrolle, resultado de la transposición de la Directiva Solvencia II, deben ser integradas con los desarrollos normativos y las medidas de ejecución dictadas por la Comisión Europea y por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en un amplio conjunto de cuestiones como la valoración de activos y pasivos, provisiones técnicas, los fondos propios, el cálculo del capital de solvencia obligatorio, modelos internos, el capital mínimo obligatorio, las normas de inversión, el sistema de gobierno, el capital adicional, la información a efectos de supervisión, la transparencia de la autoridad supervisora, la solvencia de los grupos de entidades así como la determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con las disposiciones de la Directiva Solvencia II. . »

Este enfoque se constata en la jurisprudencia del TJUE, destacando la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos tres apartados:

«48 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2018, Sofina y otros, C-575/17, EU:C:2018:943, apartado 23 y jurisprudencia citada).»

"80 Un normativa nacional que permite la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes facilita así la acumulación de capital de dichos fondos, mientras que, tal y como señaló el Gobierno alemán en la vista, todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las

primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro.

108 Pues bien, tal como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, la adquisición de participaciones por un fondo de pensiones y los dividendos que percibe a este respecto sirven principalmente para mantener los activos y garantizar las provisiones que ha constituido gracias a una mayor diversificación y a una mejor distribución del riesgo al objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de pensiones de jubilación frente a sus afiliados. Así pues, esta adquisición de participaciones y estos dividendos son, en primer lugar, un medio empleado por los fondos de pensiones para poder cumplir sus compromisos en materia de pensiones y no un servicio que preste dichos afiliados.»

El art. 24.6 TRLIRNR no establece distinción alguna, habla literalmente de "gastos deducibles" y las provisiones técnicas lo son. El problema será, en consecuencia, determinar si las provisiones técnicas cuya deducción se pretende están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y si tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Entendemos que cabe establecer un vínculo directo por cuanto la dotación de esta provisión tiene su causa en la obligación de asignar a los tomadores/beneficiarios parte de los beneficios obtenidos por la entidad aseguradora, ya sea de los beneficios financieros derivados de todas o una parte de sus inversiones o de los técnicos vinculados a la siniestralidad de toda o parte de la cartera de seguros. Mientras la primera modalidad es típica de los seguros de vida-ahorro, la segunda es habitual en los seguros de vida-riesgo u otros seguros personales (enfermedad, accidentes).

Esta conclusión está avalada en supuestos similares reconocidos por la jurisprudencia del TJUE:

En ese sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos dos apartados:

*«74. En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación relativa a la diferente situación de los fondos de pensiones residentes y no residentes en cuanto a la posibilidad de que se tengan en cuenta las dotaciones a las provisiones para hacer frente a los compromisos en materia de pensiones como gastos profesionales, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 2011, *Schröder*, C-450/09, EU:C:2011:198, apartado 40; de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 37, y de 24 de febrero de 2015, *Grünewald*, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 29).*

79 Así pues, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que existe una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente, en la medida en que los dividendos utilizados para las provisiones técnicas no incrementan el resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones, extremo que fue confirmado por el Gobierno alemán en la vista. En efecto, según dicho Gobierno, una gran parte de los beneficios obtenidos a través de la inversión debe beneficiar al afiliado, lo que quiere decir que no pueden permanecer en el activo del fondo de pensiones y que los ingresos son la condición para el gasto en concepto de provisiones».

Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional, qué gastos se pueden considerar directamente vinculados a la actividad en cuestión.

Precisamente, dentro de esa facultad de "apreciación" reconocida por la jurisprudencia comunitaria anteriormente transcrita, se encuentra la sentencia de instancia, quien procede a ponderar las circunstancias concurrentes tales como la correspondiente trazabilidad de las inversiones.

La recurrente realizó un esfuerzo probatorio que ha sido valorado por el tribunal de instancia ponderando de manera razonada los elementos probatorios puestos a su disposición.

No está demás, reproducir el apartado 49 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, en la que se declara que

«el mero hecho de que dicha prueba ofrezca mayor dificultad, no es motivo suficiente para que un Estado miembro deniegue de forma absoluta a los no residentes, sujetos pasivos por obligación real, una deducción que concede a los residentes, sujetos pasivos por obligación real, puesto que no puede excluirse a priori que un no residente pueda aportar los justificantes pertinentes que permitan a las autoridades tributarias del Estado miembro de tributación comprobar, de manera clara y precisa, la existencia y la naturaleza de los gastos



profesionales cuya deducción se solicita (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de enero de 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, apartado 53, y de 26 de mayo de 2016, Kohll y Kohll-Schlesser, C-300/15, EU:C:2016:361, apartado 55).»

En nuestra sentencia 13 de noviembre de 2019, rec. cas. 3023/2018, nos hicimos eco de que el TJUE ha señalado que *«las autoridades tributarias de un Estado miembro están facultadas para exigir al contribuyente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si se cumplen los requisitos de una ventaja fiscal prevista por la legislación pertinente y, por consiguiente, si procede conceder o no dicha ventaja. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía fiscal de los Estados miembros debe hacerse respetando las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, especialmente las establecidas por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, lo cual entraña que los potenciales beneficiarios no residentes no pueden estar sujetos a cargas administrativas excesivas que les impidan de forma efectiva beneficiarse del régimen fiscal de que se trata».*

La evolución de la normativa española, la jurisprudencia del TJUE y de esta misma Sala, avalan una interpretación favorable a la pretensión de las aseguradoras desde el prisma de la libertad de circulación de capitales. En resumen, como consecuencia de la dotación de las provisiones técnicas, las empresas residentes en España se benefician de un crédito fiscal, solicitando la devolución de las retenciones en exceso sufridas. Posibilidad que debe ser también concedida a las entidades aseguradoras no residentes sin establecimiento permanente:

En nuestra sentencia de 5 de junio de 2018, rec. cas. 634/2017 declaramos que:

«la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 24 de la Ley del IRNR, como argumenta la sentencia de instancia.

Como culminación de cuanto hemos expuesto, debemos afirmar que la vulneración del Derecho de la Unión Europea es aquí de doble signo: de un lado, en su aspecto material, porque las sociedades no residentes perceptoras de dividendos de empresas residentes son discriminatoriamente tratadas en relación con esas mismas empresas si fueran residentes, como consecuencia de que la base imponible del impuesto real se calcula en las primeras sobre el importe íntegro (artículos 23 de la Ley 41/1998 y 24 del Texto Refundido de 2004), sin posibilidad alguna de deducir los gastos o provisiones».

De la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), interesan los siguientes dos apartados:

«64. Por consiguiente, es necesario distinguir las diferencias de trato permitidas en virtud del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), de las discriminaciones prohibidas por el apartado 3 de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para que una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia Santander Asset Management SGIIIC y otros, C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, apartado 23 y jurisprudencia citada).

67. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir del momento en que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a los contribuyentes residentes sino también a los no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados contribuyentes no residentes se asemeja a la de los contribuyentes (véanse, en este sentido, las sentencias Denkvit Internationaal y Denkvit France, C-170/05, EU:C:2006:783, apartado 35; Comisión/Italia, C-540/07, EU:C:2009:717, apartado 52; Comisión/España, C-487/08, EU:C:2010:310, apartado 51; Comisión/Alemania, C-284/09, EU:C:2011:670, apartado 56, así como el auto Tate & Lyle Investments, C-384/11, EU:C:2012:463, apartado 31).»

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960) son destacables los siguientes apartados:

« 49 (...) el hecho de que un Estado miembro dispense a los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes un tratamiento menos favorable en comparación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes puede disuadir a las sociedades establecidas en un Estado miembro distinto de ese primer Estado miembro de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 33; de 22 de

noviembre de 2012, Comisión/Alemania, C-600/10 , no publicada, EU:C:2012:737 , apartado 15, y de 2 de junio de 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14 , EU:C:2016:402 , apartado 28).

50 Constituye un tratamiento menos favorable la aplicación a los dividendos abonados a fondos de pensiones no residentes de una carga impositiva mayor que la que soportan los fondos de pensiones residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 48). Lo mismo sucede cuando los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes se benefician de una exención total o parcial, mientras que los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes se someten a una retención en origen definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartados 32 y 33).

51 Según se desprende de la resolución de remisión, en virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, los fondos de pensiones están sujetos, por lo que respecta a los dividendos que se les distribuyen, a dos regímenes de tributación diferentes, cuya aplicación depende de su condición de residente en el territorio del Estado miembro de la sociedad que distribuye los dividendos.

56 De ello se deduce que, debido a esta deducción de las provisiones correspondientes a los dividendos percibidos de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre sociedades, los dividendos percibidos por los fondos de pensiones residentes no incrementan dicha base imponible, o la incrementan de manera muy reducida.

63 Esta disposición debe interpretarse en sentido estricto, en la medida en que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en el que residen o del Estado miembro en el que invierten sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado FUE. En efecto, la excepción establecida en el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), está limitada, a su vez, por el artículo 65 TFUE , apartado 3, que prescribe que las disposiciones nacionales a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo «no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal como la define el artículo 63 [TFUE]» (sentencia de 10 de abril de 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12 , EU:C:2014:249, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).»

El reconocimiento del carácter deducible de la provisión de participación en beneficios y para extornos regulada en el art. 38 del ROSSP, se enmarca dentro del principio general de adaptación de la normativa española al acervo legislativo y jurisprudencial comunitario, e impone que las personas jurídicas no residentes, pero que residan en países de la UE, para determinar la base imponible de los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente puedan deducir los gastos conforme a lo previsto en la LIS, ciertamente, siempre que se acredite, que los mismos están relacionados directamente con los obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.

Amparar un planteamiento como el auspiciado por la administración tributaria, supondría la introducción de distorsiones fiscales en directa colisión con la libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, esto es, consagrar un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia. No debemos olvidar, que el sistema asegurador ostenta un marco normativo armonizado (Directiva 2009/138/CE), y precisamente estamos ante un sector que precisa de ingente financiación, donde el flujo inversor entre los estados miembros resulta cada vez más indispensable para garantizar el sistema de coberturas y solvencia de la actividad aseguradora.

A mayor abundamiento, se insiste en que por la sentencia de instancia se estima la demanda puesto que se concluye que la entidad aseguradora ha realizado un esfuerzo probatorio serio y riguroso para acreditar la correlación del gasto que se pretende deducir con los ingresos obtenidos, extremo que soslaya de por entero en el escrito de interposición.

CUARTO. Doctrina que se fija

Por las razones expuestas, la doctrina que se fija es la siguiente:

«Las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que sólo realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE, en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España.»

QUINTO.- Pretensiones deducidas y pronunciamientos que solicitan

La pretensión de la Abogacía del Estado es que la sentencia de instancia sea casada y el recurso contencioso-administrativo sea íntegramente desestimado.

La pretensión de R+V ALLGEMEINE VERSICHERUN se concreta en que se acuerde no haber lugar al recurso de casación.

Por todas las razones expuestas, acogemos la pretensión de R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, de manera que se confirma la sentencia recurrida, lo que comporta que las resoluciones y actos de los que trae causa quedan anulados.

SEXTO. - Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero. Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico cuarto de esta sentencia.

Segundo. No haber lugar al recurso de casación núm. 5786/2024, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el abogado del Estado contra la sentencia dictada el 10 de mayo de 2023, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el procedimiento 884/2019, sobre el impuesto sobre la Renta de No Residentes, ejercicios 2011 a 2013, sentencia que se confirma, lo que lleva aparejada la anulación de las resoluciones y actos de los que trae causa.

Tercero. No hacer imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.